

1501311-09.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... juntos da maconha. Nega a prática do tráfico e, quanto ao cultivo dos pés, disse que fumava nos fundos e jogava as sementes no jardim. Fugiu, pois assustou-se com o barulho no portão, mas não sabia que era polícia. Não fugiu porque é "enrolado com o tráfico", mas com medo que pudesse ser um ladrão. Não é verdade que sua esposa tentou impedir que fosse preso pela polícia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501311-09.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501311-09.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259367/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 20417293 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2119/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2259367 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY FILIPE MARQUES ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WESLLEY FILIPE MARQUES ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e §1.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 06 horas, na Rua Francisco de Azevedo Filho, n.º 110, Vila Henrique, nesta cidade e comarca de Caçapava, o réu, supostamente, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 02 porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido total de 180,82 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de

exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de constatação provisória a fls. 20/22. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, o acusado, supostamente, cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, consistentes em 10 (dez) pés de Cannabis sativa L. (maconha), para fins de comércio.

O réu foi notificado (fls. 105), apresentou defesa prévia (fls. 102/104), sendo recebida a denúncia em 21/01/22 (fls. 116) e o acusado citado pessoalmente.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha do juízo, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente, conforme adiante demonstrado.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação Provisória (fls. 20/22), Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111) e pela prova oral coligida em juízo. .

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, WESLEY FILIPE MARQUES ROCHA disse que tem 25 anos, é casado, não tem filhos, já foi processado na adolescência e depois de atingida a maioridade. Quanto aos fatos, admitiu que havia uma porção de maconha, pés de maconha e um motor em sua residência. Disse que fumava e costumava jogar as sementes de maconha no fundo. Negou que cultivava maconha para comércio. Admitiu que a maconha era sua, pois era viciado e costumava comprar em quantidade maior para não ter que ir com frequência à biqueira. Não localizaram balança e faca em seu quarto, esclarecendo que tais petrechos estavam na cozinha. Os policiais mentiram quando disseram que encontraram os petrechos juntos da maconha. Nega a prática do tráfico e, quanto ao cultivo dos pés, disse que fumava nos fundos e jogava as sementes no jardim. Fugiu, pois assustou-se com o barulho no portão, mas não sabia que era polícia. Não fugiu porque é "enrolado com o tráfico", mas com medo que pudesse ser um ladrão. Não é verdade que sua esposa tentou impedir que fosse preso pela polícia. Não sabe quantos pés de maconha havia em sua residência. A balança era usada para pesar o pedaço que comprava; além do mais, a balança era usada por sua esposa. Usava o plástico para enrolar a droga para ela não secar. Pagou R\$600,00 pela maconha. Os policiais não se identificaram ao chegar na porta de sua residência. Foi preso dentro da padaria e colocado na viatura, onde ficou aguardando os policiais estourarem o portão e invadindo a residência. Não é verdade que autorizaram o ingresso no imóvel. Os policiais não explicaram o motivo pelo qual ingressaram no imóvel. A maconha apreendida era sua; o cultivo de maconha ficava aos fundos, mas não tinha como avistá-la pelo portão da residência.

A versão do acusado, além de frágil e inconsistente, contrasta com os demais elementos de prova.

Com efeito, o policial civil DAVID SANTOS DE OLIVEIRA, sob o crivo do contraditório, disse que, na data dos fatos, estavam dando cumprimento a mandado de prisão na casa do réu, sendo que, ao chegarem no local, bateram no portão e se identificaram como policiais. No entanto, pelo vão da grade, deu para ver o réu pulando a janela, acessando o muro dos fundos e tentando se evadir em uma padaria. Deram a volta no quarteirão e acessaram a padaria que fica aos fundos do imóvel do réu, onde Wesley tentou se evadir. Nesse momento, foram contidos pela esposa do réu, de nome Denise. Ao indagarem a esposa do réu, ela disse que não havia nada de ilícito na residência. No entanto, nos fundos do terreno, colado com a parede, localizaram dez pés de maconha cultivados com um metro de altura. Na sala, apreenderam uma porção de maconha solta para consumo. No quarto do casal, localizaram metade de um tijolo de maconha, uma balança de precisão, uma faca e um rolo de plástico insulfilm. Também localizaram um motor de uma moto produto de roubo. Ambos, isto é, marido e mulher foram conduzidos à delegacia de polícia. Na delegacia, em contato com a vítima da moto, essa reconheceu o réu como sendo um dos

autores do roubo. O réu tem uma ficha extensa por tráfico desde a adolescência, mas o declarante nunca o prendeu. Foram cumprir um mandado de prisão por tráfico. Na residência, não havia mais ninguém. Ao tentar pular o muro, o réu provavelmente torceu o pé. Adentraram à residência do réu, diante da fundada suspeita provocada pela fuga ao pular o muro. Foi a esposa do réu que abriu o portão e autorizou a entrada no imóvel. Havia denúncia de tráfico contra a residência do réu, tanto que recentemente foi feita uma operação nessa mesma rua, onde costuma haver rotineiro tráfico. A maconha encontrada nos fundos do imóvel estavam juntas, agrupadas e bem adubadas. O acusado disse que a maconha era para seu próprio consumo, embora ele possuísse passagem por tráfico.

Em correspondência de entendimento, em juízo, o investigador de polícia ADRIANO DOS SANTOS COSTA confirmou que, no dia, em cumprimento a mandado de prisão em desfavor do réu, ao chegarem em seu endereço, um dos colegas viu o acusado se evadindo pelo muro da residência. Diante disso, seu parceiro deu a volta no quarteirão e os policiais chegaram em uma padaria que faz fundos à casa do réu, que intentou sair dali, mas acabou sendo preso. A partir daí, foram à residência do réu, o qual, juntamente com sua esposa franquearam a entrada da polícia, onde localizaram alguns materiais ilícitos no quintal, a saber, pés de maconha; além do mais, em um quarto, apreenderam um tijolo de maconha, uma balança de precisão, uma faca e um rolo de filme plástico usado comumente para embalar entorpecentes. Salvo engano, foi apreendida quantia em dinheiro na residência. Indagado sobre as drogas, a esposa do Wesley disse que não sabia da existência do tijolo de maconha no imóvel. Wesley disse informalmente que o entorpecente era para consumo do casal. Não conhecia o acusado anteriormente. Não se recorda qual a natureza do mandado de prisão cumprido naquela data. Reafirma que o casal autorizou o ingresso da polícia na residência. Prenderam o acusado no interior de uma padaria tentando fugir após se evadir de sua residência pulando o muro. Tiveram dificuldade em algemar o réu, pois sua esposa ofereceu uma leve resistência. Adentraram à residência do réu diante da suspeita levantada pelo acusado ao fugir e porque franqueada a entrada no imóvel pelo casal. Não havia mandado para entrar na casa, mas reafirma que o réu foi visto se evadindo pelos fundos. O declarante estava apoiando outra equipe e, por isso, não sabe dizer se havia denuncia anterior de tráfico contra o réu, mas esclarece que a rua é conhecida como ponto de drogas. A esposa do réu autorizou e acompanhou as buscas no interior da residência. Os demais objetos foram encontrados embalados juntos com a droga apreendida no dormitório do acusado. Salvo engano, o dinheiro foi encontrado em outro imóvel. Os pés de maconha estavam nos fundos da casa. Foram seus colegas quem encontraram os pés de maconha no local. Como praxe, ao chegarem no local, identificaram-se como policiais. Reafirma que a esposa do réu acompanhou as buscas no imóvel. O declarante não retornou à residência após a condução do réu; acredita que outra equipe retornou ao local.

A informante da defesa DENISE FERREIRA DA COSTA, em juízo, disse que é casada com o réu. No dia dos fatos, levantou-se, foi à padaria e, enquanto trabalhava, escutou um barulho muito forte no portão de sua residência e os seus dois cachorros latindo. Após isso, seu marido pulou o muro e foi detido pela polícia no interior da padaria onde a declarante trabalha antes mesmo de conseguir conversar com ele. Seu marido pulou o muro e a polícia chegou uns dois ou três minutos depois. Seu marido estava desesperado, com muito medo e mancando de uma das pernas. A declarante não tentou evitar a prisão de seu marido; admite, apenas, que ficou desesperada e acabou correndo em direção aos policiais, trombando com os policiais. Convive com Wesley há oito anos. Wesley não trafica entorpecente e ambos são apenas usuários. Seu marido nunca foi preso por tráfico, tampouco na adolescência. São usuários de maconha e ela e o marido sempre trabalharam para adquirir seu entorpecente. Após a prisão de seu marido, os policiais arrombaram o portão de casa. A declarante presenciou os policiais chutando o portão e invadindo a residência. A maconha encontrada estava em seu quarto e foi a declarante quem indicou seu local aos policiais. Havia um motor na residência adquirido pelo seu marido de uma pessoa qualquer. Não sabe se seu marido foi reconhecido como um dos autores do roubo desse motor, esclarecendo que ele estava com a perna machucada por ocasião desse fato. Seu marido não lhe explicou o motivo dele ter fugido da

polícia, imaginando que “por medo” das pancadas no portão. Não sabe o motivo pelo qual os policiais não invadiram a residência no momento em que viram Wesley se evadindo pelo muro aos fundos. Wesley foi preso no interior da padaria onde a declarante trabalha e imediatamente colocado na viatura. Nenhum policial solicitou autorização para ingressar em sua residência. A declarante não estava com a chave da casa no momento. A declarante acompanhou a primeira revista na casa pelos policiais, mas a segunda vistoria não foi acompanhada por ninguém. Essa segunda vistoria não foi autorizada por ninguém e soube de sua ocorrência pelos seus familiares e vizinhos.

Como se vê, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos do processo de n.º 0000052-91.2017.8.26.01011, policiais civis foram até a residência de WESLLEY, onde viram o acusado pulando o muro do imóvel para tentar fugir da abordagem policial. No entanto, os agentes civis fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o acusado no interior da padaria onde trabalha sua mulher. Comprovou-se que, no interior da residência do acusado, após franqueado o ingresso no imóvel, foram encontrados 10 pés de maconha e, no quarto do casal, um pedaço de tijolo e uma porção menor desta mesma substância, além de um rolo de plástico filme, uma faca, uma balança e a quantia de R\$ 200,00 em dinheiro. Ainda no quarto do casal, localizou-se um motor de motocicleta produto de roubo ocorrido em Taubaté.

A esse respeito, malgrado o esforço da combativa Defesa, não há qualquer ilegalidade na forma como se deu o ingresso dos policiais civis na residência do réu, pois, em se tratando o tráfico de entorpecentes de crime permanente, dispensável a preexistência de mandado judicial, sem que isso implique ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio.

Segundo a jurisprudência, em casos como o presente, afastada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional insculpida no artigo 5º, VI, que preconiza que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”, de modo que aquele que guarda e tem em depósito drogas, com nítida finalidade mercantil, tal como WESLLEY, encontra-se em situação flagrancial permissiva do ingresso na residência, inclusive sem autorização do morador ou mandado judicial. Ainda que assim não fosse, é importante considerar, à luz dos depoimentos dos investigadores de polícia DAVID SANTOS e ADRIANO DOS SANTOS, que o ingresso na residência do réu se deu com a autorização de sua esposa DENISE.

E não há nenhum indício de insinceridade na palavra das testemunhas de acusação, as quais prestaram depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, não sendo crível que forjariam evidências em desfavor do réu, pessoa que sequer conheciam.

Quanto aos depoimentos de testemunhas que exerçam função no combate diário à criminalidade, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Nesse sentido: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por outro lado, conquanto a informante DENISE tenha dito que não autorizou o ingresso da Polícia Civil na residência, é evidente que seu depoimento deve ser analisado com ressalvas, já que possui nítido interesse em inocentar o marido.

Por fim, é inquestionável que o ingresso na residência pela polícia se deu com a autorização de seus moradores, pois, por certo, se fosse para invadir o imóvel de forma clandestina, os policiais já o teriam feito no exato momento em que viram WESLLEY se evadindo aos fundos da residência pelo muro, mas preferiram realizar sua

prisão e ingressar licitamente no imóvel com o consentimento de sua responsável. Portanto, fica afastada a alegação de nulidade processual das provas por derivação. No mais, as circunstâncias da prisão com a tentativa de fuga do acusado, o encontro de considerável quantidade de drogas, dinheiro, petrechos de pesagem e embalagens revelam que WESLLEY estava envolvido com o narcotráfico e que os entorpecentes apreendidos estavam destinados para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que “[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]” (RT 729/542).

Bem por isso, a alegação de que WESLLEY é usuário de maconha não afasta sua condição de traficante desde a adolescência, já que é de sabença geral que muitos usuários se envolvem com o tráfico à vista da necessidade de sustentar o próprio vício.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Contudo, no tocante à conduta típica do artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei de Drogas, que incrimina aquele que “semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas”, é o caso de absolvição do acusado, porquanto a condenação pelos dois delitos, em uma única conduta (artigo 33, caput, e artigo 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06), penaliza o agente duas vezes, o que é vedado constitucionalmente.

Ora, o réu foi surpreendido, nas mesmas circunstâncias fáticas, guardando e mantendo em depósito drogas e cultivando 10 pés de maconha em sua residência para fins de tráfico, sendo, portanto, o caso de aplicar o princípio da consunção, sob pena de bis in idem.

Outrossim, a cultivation das plantas, em não havendo notícia da venda/armazenamento de outros entorpecentes, como no caso, é simples meio para a traficância, de modo que fica absorvida a conduta do artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, confira-se acórdão de relatoria do e. Desembargador Ivan Sartori:

“...em que pese o esforço da acusação, não se pode falar em concurso de crimes nos termos em que lançado, porquanto a conduta descrita no §1º, I, do art. 33 é aqui abarcada pela do 'caput', porque tudo ocorreu num mesmo contexto, encontrando-se, além das drogas e petrechos, substância destinada a sua preparação/refino. Daí a consunção. Realmente, como bem anotado pelo douto magistrado sentenciante: '(...) Os fatos descritos na inicial acusatória [tendo em depósito e guardando {...} matéria prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas {...}] não se mostram autônomos para serem tipificados no dispositivo legal em tela. Ao contrário, representam apenas uma etapa da concretização do crime tipificado no artigo 33, caput, da mesma Lei, sendo por ele absorvido. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal (...) (HC100946, Relator: Min. LUIZ FUX, Relator p/Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011 ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2012 PUBLIC 27-02-2012 RTJ VOL -00224-01 PP-00483). No caso concreto, foi apreendida uma porção de cafeína, que não pode ser entendida como caracterizadora do tipo penal em comento, pois encontrada no mesmo contexto em que praticado o delito de tráfico, devendo ser considerado como instrumento para a realização deste.” (fls. 150/1).” (Apelação Criminal nº 0035689-57.2014.8.26.0506 4ª Câmara Criminal, j. 26.07.2016).

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira etapa, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do réu, a saber, 02 porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso líquido total de 180,82 gramas, além do cultivo, no mesmo contexto fático, de 10 pés de Cannabis sativa L. (maconha), para fins de comércio, a demonstrar alto grau de reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, a saber, 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).

Ainda, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, Dje 21/09/2017.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência específica (artigo 61, I, do Código Penal), já que o acusado possui condenação anterior definitiva por tráfico de entorpecentes nos autos do processo de nº 52-91.2017 (fls. 48/49). Incide, outrossim, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Com efeito, não se pode negar que WESLLEY se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade.

Desse modo, realizo o acréscimo das penas em 1/3, ensejando o total de 07 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento e/ou diminuição. A esse respeito, é incabível o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois é evidente que WESLLEY não se trata de traficante eventual, isto é, de um novato no crime sem muita experiência.

Primeiramente, trata-se de réu reincidente específico, uma vez que condenado em definitivo por tráfico de entorpecentes nos autos do processo de nº 52-91.2017 (fls. 48/49).

Ademais, o próprio réu WESLLEY admitiu em seu interrogatório judicial possuir passagem anterior pela Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Muito embora não seja possível sopesar tal circunstância para considerá-lo reincidente ou portador de maus antecedentes, conforme entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça, não há nenhum óbice para levá-la em consideração como indicativo de dedicação do réu às atividades criminosas, a reforçar a necessidade de afastamento do privilégio.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a

justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017 grifo nosso).

HABEAS CORPUS Nº 460.141 - SP (2018/0180069-2) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos - 30 eppendorfs de cocaína (44,1g) e 71 invólucros de maconha (1,190kg) -, assim como nos anteriores registros da prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico e de roubo, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 6. In casu, a dedução do período de prisão cautelar não tem o condão de abrandar o regime prisional estabelecido, diante da presença de fundamento válido para o modo mais gravoso - a expressiva quantidade de droga. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido (HC Nº 460.141-SP - STJ - RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS - 04/09/2018).

Não se olvide que o privilégio somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado WESLLEY, conforme sobejamente demonstrado nos autos.

Fixo o dia multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

À vista da quantidade de pena aplicada ao acusado, superior a quatro anos de reclusão, bem como em face de sua reincidência específica (processo de nº 52-91.2017 - fls. 48/49) e insuficiência da medida, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, I, II e III do Código Penal.

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. I. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis

as circunstâncias e conseqüências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j . 04/09/2007, DJe 04/08/2008) - destaque nosso.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Some-se a isso que o tempo de prisão preventiva do réu pelo atual processo é insuficiente para que faça jus à fixação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal c.c artigo 112 da LEP.

Por derradeiro, a necessidade no caso concreto de fixação do regime mais gravoso (fechado) encontra-se fundada no artigo 33, § 3º, do Código Penal e no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 em função da gravidade concreta do delito, consubstanciada pela considerável quantidade de drogas e pés de maconha apreendidos e pela flagrante periculosidade do réu, reincidente específico (processo de nº 52-91.2017 - fls. 48/49) que vem se dedicando ao tráfico desde a adolescência.

Nessa esteira, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Observa-se que, apesar da primariedade do paciente e de o montante da pena (5 anos de reclusão) comportarem, em princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se lastreada no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela eleva da quantidade dos entorpecentes apreendidos, elemento que, inclusive, foi valorado na terceira etapa da dosimetria da pena, quando do não reconhecimento do privilégio. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido .(HC 416.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu WESLLEY FILIPE MARQUES ROCHA ao cumprimento das penas de 07 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 777 dias-multa, no menor valor unitário, com correção na forma da lei, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, ABSOLVENDO-O da prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso II da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Conforme acima fundamentado, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, ora reforçados com a presente condenação, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03. Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II,

“b” do Código Penal e no artigo 62 da lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários no maior valor de referência.

P.R.I.C.

Caçapava, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA